

1500738-60.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eldean Almeida de Oliveira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ELDEAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500738-60.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500738-60.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eldean Almeida de Oliveira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ELDEAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06, em concurso material (art. 69, CP).

Segundo consta da denúncia, no dia 06 de maio de 2020, por volta das 06h20min, na Rua Júlio Roque, próximo ao numeral 69, centro da cidade de Luiziânia-SP, o acusado trazia consigo droga para a entrega de terceiros, consistente em uma porção de maconha contendo 3,84 gramas, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta ainda que nos dias anteriores e no dia 08 de julho de 2020, por volta das 17h30min, no quintal da residência localizada na Rua Júlio Roque, n. 69, município de Luiziânia, o acusado cultivava sem autorização legal ou regulamentar plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas, consistentes em 22 plantas de maconha, pesando o total de 39,33 gramas.

O acusado compareceu espontaneamente aos autos pugnando pela desclassificação para a conduta de usuário (fls. 132/135).

A denúncia foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2022 (fls. 137/139).

Na instrução criminal foram ouvidas três testemunhas. Ao final foi interrogado o acusado.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas em relação ao primeiro fato e a condenação do réu pela conduta equiparada ao tráfico de drogas em relação ao segundo fato, com a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Já a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas ou pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (fls. 180/182).

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em relação ao segundo delito descrito na denúncia, a materialidade do crime de tráfico de drogas é positiva, tal como se extrai do B0 de fls. 62/63, do auto de exibição e apreensão de fls. 64, bem como do laudo pericial de fls. 67/69 que indica a apreensão de 22 "pés" de maconha (totalizando 39,33 gramas).

Em relação ao primeiro delito, não obstante a apreensão de entorpecente (laudo de fls. 08/09), não vislumbro comprovação de traficância no caso, considerando que foi apreendida apenas uma pequena porção, sem outras circunstâncias a evidenciar a traficância. Assim, em relação ao primeiro fato, de rigor a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Friso que não há contradição entre as duas afirmações, posto que não raras vezes o pequeno traficante também é usuário de drogas.

Por sua vez a autoria foi confirmada pelos depoimentos colhidos tanto na fase administrativa, quanto em juízo, senão veja-se.

Em juízo a testemunha PC Manoel Izael de Oliveira disse que tanto a polícia civil quanto a polícia militar tinha informações de que o réu Eldean estavam traficando, junto com sua mãe, Elza, que morava perto. Uma vez a PM abordou ele e encontraram uma porção de droga e dinheiro. Pediram mandado de busca. Foram cumprir mandado de busca e na casa dele nada de ilícito foi encontrado, mas no fundo do quintal encontraram vinte e dois pés de maconha. O réu disse que plantou a droga para consumo próprio. Não tinham informações de que o réu plantava maconha. Foi a polícia militar que efetuou a apreensão.

A testemunha Paulo Cesar Amorim disse que estavam em patrulhamento pelo município de Luiziânia, quando encontraram o réu saindo da residência. Já era sabido que o réu estava promovendo o tráfico de drogas em Luiziânia, até levando para vender na roça. O réu estava com uma mochila com seus pertences para ir para a roça. Dentro da mochila tinha uma sacola contendo uma porção de maconha. O réu disse que era para uso. Foram apreendidos também R\$ 365,00. As denúncias eram de que a mãe dele também fazia tráfico e ele também. Não se recorda se o depoente já fez outro B0 de droga. O horário da abordagem era umas 6h. Só estava ele saindo da casa.

A testemunha Fernando Augusto Marques Gouveia disse que recebiam várias denúncias de transeuntes e de usuários que o réu estava vendendo entorpecente pela cidade. Em patrulhamento avistaram ele e abordaram ele em razão dessas denúncias. Em vistoria na mochila dele encontraram uma porção de maconha e trezentos e sessenta e cinco reais em notas diversas. Após isso o réu foi levado ao DP. A abordagem ocorreu logo de manhã, após às 6h da manhã, 06 e meia. Foi na Rua São Roque, João Roque em Luiziânia. O réu era conhecido nos meios policiais por tráfico. Recorda-se que

estava só ele na via pública, ele estava indo trabalhar para a roça. Na fase administrativa o réu disse que "quanto ao boletim de ocorrência nº 560/2020, relata que há cerca de três meses, recordando-se ser uma segunda-feira, por volta das 06h horas da manhã, estava saindo de sua residência para ir trabalhar, quando acabou sendo abordado por Policiais Militares em frente a sua casa; que foi questionado se trazia consigo algo de ilícito, ao que respondeu que dentro de sua mochila havia uma pequena porção de maconha que era para seu uso; que os Policiais Militares revistaram sua bolsa, e lograram êxito em localizar o entorpecente, bem como R\$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco) reais em dinheiro; acerca do dinheiro relatou que era fruto de seu serviço como trabalhador rural, e que o estava levando consigo porque no retorno do trabalho iria pagar o aluguel e uma conta de água; que não possuía nenhum recibo que comprovasse sua versão; diante dos fatos, foi conduzido até o Plantão Policial, na cidade de Penápolis, para registro da ocorrência; que após o registro foi liberado; já quanto ao boletim de ocorrência nº 65/2020, relata que decorridos cerca de dois meses do primeiro fato, estava em sua residência, quando compareceram naquele local Policiais Civis; que eles informaram que estavam de posse de um mandado de busca, sendo que o interrogado autorizou a entrada dos mesmos em sua residência e acompanhou a realização da busca; que dentro de sua residência nada de ilícito foi encontrado, porém quando da vistoria em seu quintal, acabaram por localizar vinte e duas plantas de maconha, as quais encontravam-se plantadas no solo; indagado sobre os pés de maconha, respondeu que o próprio interrogado as havia plantado, e que seriam para seu consumo; não se recorda onde conseguiu as sementes; que as plantas foram todas arrancadas e apreendidas; que foi registrado boletim de ocorrência acerca do fato; afirma que não pratica o comércio de drogas; que possui uma filha de 3 anos de idade, a qual reside com o interrogado e sua amásia; nunca foi processado; aceita receber notificações e intimações através do "Whatsapp" (18) 99657-6762" (fls. 70). Em juízo disse que fuma maconha e estava levando uma porção para fumar no serviço. O depoente sempre levava para a roça para consumir. Nunca vendeu. Tinha a plantação de maconha no fundo da casa, ia testar o chá para ver se curava a asma. Pegava nas mãos de segundos a maconha e sempre vinha algumas sementes, aí jogava no quintal para plantar. Ia usar a plantação para chá e para fumar também. Pegava a droga no quintal e fumava junto com os amigos. Não vendia, mas usava a droga com os amigos no quintal. O dinheiro que foi apreendido era de seu pagamento que ia colocar na conta. Na residência morava com sua mulher e sua filha.

Pois bem.

Em relação ao segundo fato narrado na denúncia o caso é de condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06.

É fato incontroverso que o acusado plantou no quintal de sua residência 22 (vinte e dois) pés de maconha. O tamanho da plantação revela que o produto do cultivo não atenderia apenas ao consumo próprio do acusado. Tanto é assim que o acusado confirmou que com regularidade fornecia droga a seus amigos para consumirem, não se tratando de fornecimento eventual.

Assim, preenchidos os requisitos do tipo penal, de rigor a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06.

No mais verifico que o réu é primário, não possuindo maus antecedentes. Também não há comprovação de que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosas. Sendo assim, de rigor a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, no máximo legal.

Por outro lado, em relação ao primeiro fato narrado na denúncia, não obstante a apreensão de uma porção de entorpecente não há outros elementos a revelar traficância por parte do acusado naquele momento específico. Mesmo considerando as denúncias prévias, fato é que o réu apenas estava caminhando na rua com uma porção de maconha na mochila, sendo crível a versão de que a porção destinava-se a seu consumo. Friso que não há contradição com a condenação por traficância já exposta acima, posto que é comum que os pequenos traficantes também sejam usuários de droga.

Assim, em relação ao segundo fato o caso é de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, com a condenação à pena de advertência, diante da

primariedade.

Passo à dosimetria da pena.

O tipo penal previsto no art. 33, §1º, II, da Lei de Drogas prevê pena de reclusão de 05 a 15 anos e de 500 a 1500 dias-multa.

Em relação à quantidade e natureza da droga apreendida nada a valorar. A culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui maus antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é normal à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. No que pertine às consequências, certo é que não restaram caracterizadas outras consequências além daquelas próprias do tipo penal.

Finalmente, não há que se valorar o comportamento da vítima, pois se trata de crime vago, em que a vítima é a sociedade como um todo.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausente qualquer agravante. Presente a atenuante da menoridade relativa, que deixo de valorar, posto que a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Ausente qualquer causa de aumento de pena. Presente a minorante prevista no art.

33, §4º, da Lei de Drogas, tal como já fundamentado acima, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a situação econômica do acusado, o dia-multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, que previa necessariamente o regime inicial fechado para os crimes hediondos.

Ademais, no HC 118.533, recentemente o STF firmou o entendimento de que o tráfico "privilegiado" do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não é crime hediondo.

Sendo assim, nos termos do art. 33, §3º e 59, ambos do CP, tendo em vista a pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO (ART. 33, do CP).

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada à ré por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP - à razão de uma hora por dia de condenação, nos termos a serem definidos pelo juiz da execução.

Diante da pena aplicada a segregação cautelar mostra-se desproporcional. Sendo assim concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim CONDENAR o réu ELDEAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e do delito de tráfico "privilegiado" de drogas (art. 33, caput, c/c art. 33, §1º, II e §4º, ambos da Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP, e, por consequência, às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, além da pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Disposições finais:

a) Determino a incineração da droga apreendida, caso tal medida ainda não tenha sido tomada pela autoridade policial;

b) Devolva-se o dinheiro apreendido ao réu, eis que apreendido no primeiro fato, que foi desclassificado para o art. 28 da Lei de Drogas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, diante da situação financeira apresentada, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a multa, intimando-se para pagamento; c) Expeça-se guia de recolhimento definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.

Penápolis, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA